

2.- En relación a la atribución del Procurador del Tesoro para desistir de un recurso de apelación, debo señalar que a partir de la causa "Benegas..." (Auto 20/2003) admití la interpretación sostenida por la Sala y ratificada por la propia demandada quien, a través de diversos precedentes, siempre acompañó el acto de autorización del Poder Ejecutivo o del Fiscal de Estado, tal como se deriva de los artículos 144 inciso 1º de la Constitución Provincial y 6, 21 y concordantes de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado 7854 (Mayoría, Dr. Lafranconi).

3.- Corresponde hacer lugar al desistimiento del recurso de apelación formulado por el Señor Procurador del Tesoro, pues no encuentro óbices sustanciales para derivar su incompetencia de las prescripciones de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado Número 7854 (arts. 6, 21 y cc.). Tan es así, máxime cuando en el sub lite el desistimiento del recurso no genera responsabilidad patrimonial a la Provincia de Córdoba, por los gastos causídicos, pues se formuló con anterioridad a que se corra traslado a la contraria (Minoría, Dr. Rubio).

T.S.J. Sala Cont. Adm. Córdoba. 31.10.03. Auto 111. Reyes, Luis César c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación. (Reseña de Paulina R. Chiacchiera Castro).

Considerando:

El doctor **Domingo Juan Sesín**, dijo:

I) Que corresponde, en primer lugar, analizar la admisibilidad del pedido de desistimiento del representante de la parte demandada a fs. 304. Tal solicitud resulta inadmisibile atento haber sido interpuesta por el Señor Procurador del Tesoro de la Provincia, sin contar con las atribuciones necesarias para postular en juicio el desistimiento del recurso de apelación por ella deducido (vid art. 6, Ley Orgánica de Fiscalía de Estado Nro. 7854). La interpretación de la normativa implicada ha sido pacífica y reiteradamente ratificada por la Provincia de Córdoba en múltiples precedentes jurisprudenciales que hicieron lugar a los desistimientos que estaban precedidos del acto de autorización (cfr. Auto N° 22/1993 "Alanis..." - Dec. Nro. 247/92; Auto N° 39/1993 "Macagno..." - Resolución F.E. Nro. 27/93; Auto N° 70/1993 "Luján..." - Dec. Nro. 2331/93; Auto N° 10/1995 "Argüello"; Auto N° 34/1995 "Leal..." - Dec. Nro. 2599/94; Auto N° 39/1995 "Fontaine..." - Dec. Nro. 2547/94; Auto N° 11/1996 "Martínez..." - Dec. Nro. 2330/93; Auto N° 17/1997 "Paulo..." - Dec. Nro. 1486/96; Auto N° 270/1997 "Villarreal..." - Dec. Nro. 1349/96; Auto N° 11/

1998 "Ampo..." - Dec. Nro. 186/97; Auto N° 80/1998 "Castro de Cabanillas..." - Dec. Nro. 533/98; Auto 122/1998 "Irusta..." - Dec. Nro. 547/98; Auto N° 2/2002 "AramburuÉ" - Dec. Nro. 1365/2001, entre muchos), como así también se han desestimado diversos planteos análogos al presente por incompetencia del Señor Procurador del Tesoro (Auto N° 111/1995 "Dolce de Abregó..." ; Auto N° 20/2003 "Benegas..." , entre otros).

II) Que en consideración a lo señalado precedentemente, corresponde analizar si el remedio intentado por la parte accionada -apelación en subsidio- procede formal y sustancialmente.

III) Que la concesión de un recurso por el Inferior no inhabilita al Tribunal de Alzada para controlar la concurrencia de los presupuestos procesales atinentes a su admisibilidad formal, aún mediando conformidad de los justiciables (Hitters, «Técnica de los recursos ordinarios», Librería Editora Platense, La Plata 1985, págs. 394 y ss.).

IV) Que en virtud de ello, corresponde revisar si el remedio intentado -recurso de apelación- ha sido deducido conforme a las condiciones de impugnabilidad exigidas por el ordenamiento adjetivo vigente. En esa labor, es dable señalar la concurrencia de obstáculos formales determinantes de la inadmisibilidad del recurso articulado por la parte demandada. Así, de conformidad con la hermenéutica del artículo 41 y lo puntualizado en la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (Ley 7182), el Legislador ha adoptado el principio de taxatividad dando hermeticidad al sistema de la ley, incorporando en ella las condiciones subjetivas, objetivas y los medios que se autorizan para revisar las resoluciones judiciales en los casos específicamente previstos (A.I. N° 250/1997 «Romanutti H. c/ Tribunal de Disciplina...», A.I. N° 100/1999 «Empresa Pampa de Achala S.R.L. c/...»). En ese marco normativo, el artículo 43 de la Ley 7182 dispone que: "Procederá el recurso de apelación sólo en las causas en que la Provincia sea parte, respecto de: a) Autos interlocutorios que declaren la inhabilitación de la instancia (art. 11º); que resuelvan la excepción fundada en el inciso 1) del artículo 24º; o que declaren perención (artículo 56º). b) Sentencias definitivas" Del texto transcrito se desprende que el Legislador ha determinado cuáles son los decisorios que considera asimilables a sentencia definitiva a los efectos del recurso de apelación, de lo que se deriva que se refiere a aquéllos que ponen fin al proceso de conocimiento, o bien, a los que impiden su prosecución, los que han sido expresamente definidos por la ley.

V) Que la Ley 7182 no prevé la interposición sub-

sidiaria del recurso de apelación (conf. art. 43). Es más, en el marco del artículo 11 -habilitación de instancia- la apelación debe ser interpuesta contra el decisorio que resuelva el recurso de reposición, no antes, pues es condición de admisibilidad que el apelante efectúe una crítica completa y razonada de los argumentos desestimatorios del recurso de reposición. El hecho que la Cámara a-quo haya dado trámite en forma conjunta a los dos remedios deducidos en autos -reposición y apelación en subsidio-, no excusaba a la interesada de articular previamente la reposición y, una vez resuelta ésta, recién entonces intentar el recurso de apelación (art. 43, C.P.C.A.) en el que ha de entender este Tribunal Superior. La decisión que resuelve el recurso de reposición -admitiéndolo o rechazándolo- es precisamente la que cumplimenta las condiciones de impugnabilidad objetiva a las que se encuentra supeditado el recurso de apelación, cuando este último es interpuesto contra una resolución recurrible. Aceptar una postura contraria implicaría tanto como admitir la posibilidad de traer a revisión de este Tribunal Superior decisiones sobre la base de agravios que bien habrían podido ser subsanados ante el Inferior, con el consiguiente desgaste jurisdiccional que no se compadece con una razonable aplicación del principio de economía procesal (conf. doctrina de esta Sala: A.I. 35/1999 «Zárate de Morales...»; Sent. 143/2000 «García...»; Sent. 148/2000 «Marcoletta...»; Sent. 219/2000 «Ledesma...»; Sent. 18/2001 «Ferreyra, Marcelo...» y Sent. 94/2000 «Ballatore...», entre muchos)*. Ello es así en la medida que es condición de admisibilidad formal de la apelación que la recurrente se haga cargo de los argumentos desestimatorios del recurso de reposición y, mediante su impugnación, demuestre el error de hecho o de derecho en el que pudo haber incurrido el Tribunal de Juicio al pronunciarse.—Solamente cuando la decisión que rechaza el recurso de reposición sea una reproducción idéntica o literal de los fundamentos del primer decreto suscripto por el Presidente del Tribunal, lo cual no acontece en autos (cfr. fs. 271), la apelante podría reeditar en su apelación idénticos argumentos a los expuestos en la reposición. En ambos casos debe, además, mediar un preliminar análisis de admisibilidad de la apelación por el Tribunal a-quo.

VI) Que las circunstancias descriptas no se verifican en el sub iudice, donde las alegaciones de la recurrente al momento de deducir los recursos de reposición y apelación en subsidio (cfr. fs. 272/275vta.) han sido atendidas a su turno por el Juxta a-quo (cfr. fs. 289/298vta.) mediante argumentos que no son idénticos a los del decreto de fecha veintiocho de diciembre

de dos mil uno (cfr. fs. 271), los cuales, con independencia de su acierto o error, no han sido objeto de réplica al tiempo de expresar los agravios de la apelación, atento el expreso desistimiento efectuado a fs. 304 por el Señor Procurador del Tesoro de la Provincia.

VII) Que no obstante las razones expuestas, el recurso de apelación deviene igualmente inadmisibile, pues como lo ha entendido la propia demandada al plantear su desistimiento, la sanción de la Ley 9078 (B.O.P. 03/01/03), desactualiza los agravios opuestos a la resolución del Tribunal de Mérito en orden a lo preceptuado por el artículo 19 del Decreto Número 2656/01.

VIII) Que a mérito de las razones expuestas y las premisas sentadas a través de su desarrollo, corresponde declarar inadmisibile el recurso de apelación en subsidio deducido por la demandada, atento que en el sub lite no se cumplimenta con la exigencia de impugnabilidad subjetiva y objetiva a que el artículo 43 de la Ley 7182 condiciona la admisión del remedio impugnativo ensayado, con costas por el orden causado atento lo novedoso de la cuestión (art. 130, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182).

El doctor **Hugo Alfredo Lafranconi**, dijo:

I) Que en relación a la atribución del Procurador del Tesoro para desistir de un recurso de apelación, debo señalar que a partir de la causa «Benegas...» (Auto N° 20/2003) admití la interpretación sostenida por la Sala y ratificada por la propia demandada quien, a través de diversos precedentes, siempre acompañó el acto de autorización del Poder Ejecutivo o del Fiscal de Estado, tal como se deriva de los artículos 144 inciso 1° de la Constitución Provincial y 6, 21 y concordantes de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado Número 7854. Prueba de tal exigencia, es por ejemplo el Decreto Número 3664 de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos (B.O.P. del 05 de enero de 1993) donde el Poder Ejecutivo autorizó al Fiscal de Estado a consentir sentencias, autos y decisiones judiciales que resuelvan las causas sobre amparo por mora administrativa, en cuanto se relacionen con la imposición de costas a cargo de la Provincia y dentro de los encuadres interpretativos contenidos en los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (art. 1°). Es claro que de admitirse la competencia del Procurador del Tesoro para desistir, el citado decreto y la Resolución Número 115 de fe-

* Ver «Torres, Luis Esteban c. Provincia de Córdoba -Plena jurisdicción -Recurso de apelación», Auto 201/02, Zeus Córdoba N° 49, 15.04.03, Tomo 2, pág. 291 N° 323.

cha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos (B.O.P. 05 de enero de 1993), serían redundantes al ordenamiento jurídico.

II) Que en relación a las condiciones de impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida por la vía de la apelación en subsidio, he venido sosteniendo reiteradamente como miembro de esta Sala (cfr. doctrina sentada in re:

"Moyano, Laura Elena c/...", Auto 166/2001; "Curarello, Pablo Ernesto c/...", Auto 167/2001; "Belzagui, Pablo René c/...", Auto Nro. 64/2002; "Aguirre, Florencio Andrés y otro c/...", Auto 91/2002; "Rodríguez, Walter Roberto c/...", Auto 98/2002; "Granza, Carlos Horacio c/...", Auto 99/2002; "Vasallo, Gabriel Fernando c/...", Auto 103/2002; "Ordoñez, Miguel Ángel c/...", Auto 104/2002; "Burgos, Roque Alberto y otro c/...", Auto 110/2002; "Quevedo, Miguel Ángel c/...", Auto 155/2002, entre otros) con relación a que el litigante puede tanto interponer reposición y rechazada ésta, apelar, cuanto deducir directamente los recursos de reposición y apelación en subsidio contra el decreto o Auto que hubiere sido dictado sin sustanciación (art. 363, C.P.C. y C., aplicable al Fuero Contencioso Administrativo por remisión del art. 13, Ley 7182) en tanto la admisión de la apelación subsidiaria no contradice la hermeticidad recursiva que impone el artículo 41 de la Ley 7182 y constituye la solución interpretativa que, por otra parte, sirve a la regla según la cual en caso de duda los recursos deben ser concedidos (conf. doctrina Sent. 143/2000 «García...»; Sent. Nro. 148/2000 «Marcoletta...»; Sent. Nro. 219/2000 «Ledesma...» y Sent. Nro. 18/2001 «Ferreira, Marcelo...»). No obstante ello, considero que las deficiencias formales expuestas en el Considerando VII) referido a la falta de un interés jurídico actual oponible al decisorio recurrido, atento la sanción de la Ley 9078 determinan por distintos motivos una misma solución, es decir, la inadmisibilidad de la apelación.

El doctor **Luis Enrique Rubio**, dijo:

I) Que corresponde hacer lugar al desistimiento del recurso de apelación formulado por el Señor Procurador del Tesoro, pues no encuentro óbices sustanciales para derivar su incompetencia de las prescripciones de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado Número 7854 (arts. 6, 21 y cc.). Tan es así, máxime cuando en el sub lite el desistimiento del recurso no genera responsabilidad patrimonial a la Provincia de Córdoba, por los gastos causídicos, pues se formuló con anterioridad a que se corra traslado a la contraria (cfr. fs. 304).

Por lo demás, la materia de agravio del recurso de apelación interpuesto en subsidio, como acertadamente

se ha puesto de relieve en los votos de los Señores Vocales preopinantes, se ha tornado abstracto por la sanción de la Ley 9078, circunstancia de la que se puede inferir que ella ha sido la causa determinante del desistimiento formulado por el Señor Procurador del Tesoro. Este último aspecto, de no aceptarse mayoritariamente la capacidad procesal para plantear el desistimiento en las específicas condiciones que surgen de autos, justifica la inadmisibilidad de la apelación por falta de un agravio actual.

Por ello, normas legales citadas y por mayoría, se **resuelve**: I.- Declarar inadmisibile el desistimiento incoado por la parte demandada. II.- Declarar mal concedido por el A-quo el recurso de apelación en subsidio al de reposición interpuesto por la parte demandada, con costas por el orden causado atento lo novedoso de la cuestión (art. 130, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182). III.- Practicar por ante el A-quo la notificación prevista en el artículo 18 de la Ley 9078.

Sesín. Lafranconi. Rubio.

Nº 555

PROCESO LABORAL. Prueba. Presunción del art. 49, C.P.T. (1). **VIAJANTE. Remuneración** (2).

1- El art. 49, CPT, consagra una presunción legal de carácter relativo -en tanto admite prueba en contrario- consistente en tener por ciertos los hechos relatados en la demanda. La presunción de veracidad implica, por mandato legal, que se presuponga la existencia real de esos hechos, eximiendo al actor de probar los extremos allí afirmados. La falta de contestación importó la pérdida de la posibilidad de introducir defensas materiales, la actividad probatoria de la demandada sólo puede dirigirse a derribar los extremos allí invocados. Si bien éstos constituyen su objeto de prueba, no están en la categoría de hechos controvertidos, ya que el silencio de la demandada no puede equipararse a la negativa expuesta concretamente en el memorial respectivo, pues ello contrariaría la solución legal plasmada en el art. 49, último párrafo CPT. Idéntica solución surge del análisis del art. 192 CPC. El silencio o las respuestas evasivas puedan ser tomadas como confesión -y no como negación-.

2- La afirmación del Sentenciante referida a que la relación laboral del viajante no permite que se presuma un pacto de sueldo fijo, carece de sustento legal. El art. 7 de la ley 14.546 define a la comisión sobre ventas como rubro esencial de la retri-